Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Canoas

Rua Lenine Nequete, 60 - Bairro: Centro - CEP: 92310205 - Fone: (51) 3472-1184 - Email: frcanoas2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5017467-52.2022.8.21.0008/RS

AUTOR: ELIANA SULZBACHER HAAS

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

Eliana Sulzbacher Haas ajuizou ação de obrigação de fazer contra **Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda**, narrando, em síntese, que é portadora de câncer de mama (CID 10 C50.9), razão pela qual solicitou tratamento ao plano de saúde demandado, que restou negado por falta de carência. Aduziu que ajuizou ação nº 5018431-79.2021.8.21.0008, que tramita perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, postulando a cobertura do tratamento em face da urgência de seu quadro clínico. Aduziu que o processo fora julgado no sentido de determinar que operadora do plano de saúde procedesse à autorização de cobertura integral do tratamento. Referiu que, posteriormente, sua médica oncologista assistente solicitou que iniciasse tratamento com a medicação ABEMACICLIBE 150mg, com a ministração de 01 (um) comprimido via oral de 12/12 horas, continuamente, durante 24 (vinte e quatro) meses. Argumentou que o fornecimento da medicação fora formalizado perante a operado, entretanto, sobreveio negativa administrativa sob o fundamento de não restar atendida a diretriz de utilização especificada no rol de coberturas obrigatórias disposta na Instrução Normativa 064 da Resolução Normativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustentou que a medicação é imprescindível ao seu tratamento, sendo abusivo o indeferimento do fornecimento do fármaco. Teceu considerações sobre o direito que entende aplicável. Em tutela de urgência, postulou o imediato fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 150mg, pelo período de 24 meses. Ao fundo, pugnou pela procedência do pedido para confirmar o pleito antecipatório deferido. Requereu a AJG. Juntou documentos (evento 1).

Foi concedida a gratuidade da justiça à autora e deferida a tutela de urgência (evento 4).

Citada, a ré ofertou contestação no evento 12 e discorreu sobre a taxatividade do rol da ANS. Referiu que, embora o fármaco ABEMACICLIBE esteja listado dentre aqueles incluídos no regime de cobertura obrigatória para tratamento quimioterápico, este não possui previsão de fornecimento para a condição clínica apresentada pela beneficiária. Sustentou que em julgamento paradigma o STJ reafirmou a taxatividade do Rol da ANS, de maneira que não há irregularidade na conduta adotada pela operadora do plano de saúde. Defendeu a legitimidade da negativa de cobertura em razão da desconformidade do requerimento com a diretriz de utilização n. 64 da Resolução Normativa n. 465/2021. Indicou o direito que entende aplicável. Pugnou pela improcedência dos pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 16).

Oportunizada a produção de provas (evento 18).

As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (eventos 22 e 23).

Intimadas, as partes afirmaram inocorrer litispendência entre este processo e o de n. 5018431-79.2021.8.21.0008 (eventos 31 e 32).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

PASSO A DECIDIR.

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que a paciente busca autorização do plano de saúde para realização de tratamento com medicação *ABEMACICLIBE 150mg* necessária para o combate da enfermidade de câncer de mama, a qual foi negada sob o seguinte argumento:

Justificativa
No tocante a solicitação do medicamento **ABEMACICLIBE**, não restou atendida a diretriz de utilização especificadas no Rol de coberturas obrigatórias dispostas nas Instruções Normativas 064 da Resolução Normativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

A prova documental coligida é suficiente para demonstrar que a paciente suporta enfermidade grave e os laudos médicos foram elaborados de forma pormenorizada pela médica assistente justificando a necessidade do tratamento (Evento 1, OUT4).

Posto isso, importa consignar que em tal relação a demandada é fornecedora de serviço e a requerente é consumidora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 2.º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

(...)

"Art. 3.º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem com os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2.º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." (Grifei)

Nesse caminho, como a negativa vem comprovada pelo documento constante do Evento 1, OUT15 Evento 1, OUT5, além das razões de contestação da requerida, tem-se como ponto controverso a existência de cobertura ou não para o fornecimento do medicamento em desacordo com as "diretrizes de utilização".

É incontroverso nos autos que o medicamento *ABEMACICLIBE 150mg* está listado na DUT n. 64 dentre aqueles quimioterápicos que possuem cobertura obrigatória (Evento 12, OUT4). Há a ressalva, no entanto, de que o fármaco é indicado para "casos avançados da doença" (evento 12, OUT4):

Da Condição da Beneficiária

Conforme relatório médico, trata-se de uma paciente que apresenta a patologia CID 10 C50, para o qual foi solicitado o uso da medicação abemaciclibe. Este medicamento se encontra listado na DUT nº 64 entre aqueles quimioterápicos que possuem cobertura obrigatória, porém para condição clínica distinta da apresentada pela beneficiária. O medicamento está indicado para casos avançados da doença.

Abemaciclibe	Mama	Tratamento de pacientes adultos com câncer de mama avançado ou metastático, com receptor hormonal positivo (HR positivo) e receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 negativo (HER2 negativo): - em combinação com um inibidor da aromatase como terapia endócrina inicial; - em combinação com fulvestranto como terapia endócrina inicial ou após terapia endócrina; - como agente único, após progressão da doença após o uso de terapia endócrina e 1 ou 2 regimes quimioterápicos anteriores para doença metastática. (Incluído pela RN nº 477, a partir de 14/01/2022)

Registre-se que o plano de saúde pode determinar quais doenças terão cobertura, mas não pode limitar as formas de tratamento indicadas pelo médico, mesmo que não previstas nas diretrizes de utilização da ANS - DUT N. 64.

Imperioso mencionar a decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, cujo relator foi o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito (Recurso Especial nº 668.216 – SP 2004/0099909-0):

Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva.

*1. **O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta.***

2. Recurso especial conhecido e provido.

Do corpo do acórdão se extrai o seguinte fragmento:

" (...) a cláusula de exclusão rompe o equilíbrio contratual e causa vantagem exagerada em favor da ré "colocando o segurado em posição de excessiva onerosidade, já que não pode dispor dos benefícios pelos quais pagou, deve tal cláusula ser declarada nula, condenando-se a ré a pagar todas as despesas feitas no tratamento (...)

*A orientação que se vem firmando, e que merece exame da Corte, é sobre esse ponto, considerando a consolidação legislativa vigente com a Lei n° 9.656/98. O que se procurou fazer, pelo menos no meu entender, foi estabelecer critério para proteger o consumidor e ao mesmo tempo assegurar a viabilidade empresarial dos planos privados de saúde. De fato, não se pode negar o direito do contrato de estabelecer que tipo de doença está ao alcance do plano oferecido. Todavia, entendo que deve haver uma distinção entre a patologia alcançada e a terapia. **Não me parece razoável que se exclua determinada opção terapêutica se a doença está agasalhada no contrato. Isso quer dizer que se o plano está destinado a cobrir despesas relativas ao tratamento, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato.** Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto **quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente.** Além de representar severo risco para a vida do consumidor. Foi nessa linha que esta Terceira Turma caminhou quando existia limite de internação em unidade de terapia intensiva (REsp n° 158.728/RJ, da minha relatoria, DJ de 17/5/99), reiterado pela Segunda Seção (REsp n° 251.024/SP, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 4/2/02). **Isso quer dizer que o plano de saúde pode estabelecer que doenças estão sendo cobertas, mas não que o tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.** Assim, por exemplo, se está coberta a cirurgia cardíaca, não é possível vedar a utilização de stent, ou, ainda, se está coberta a cirurgia de próstata, não é possível impedir a utilização de esfíncter artificial para controle da micção. O mesmo se diga com relação ao câncer. Se a patologia está coberta, parece-me inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de que a quimioterapia é uma das alternativas possíveis para a cura da doença. **Nesse sentido, parece-me que a abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o***

paciente, consumidor do plano de saúde, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno do momento em que instalada a doença coberta em razão de cláusula limitativa. É preciso ficar bem claro que o médico, e não o plano de saúde, é responsável pela orientação terapêutica. Entender de modo diverso põe em risco a vida do consumidor.

Assim, no caso, não havendo exclusão do câncer na apólice do autor, não há como impedir a cobertura do seguro para o tratamento por quimioterapia em regime ambulatorial ou de internação " (grifei).

No caso dos autos não estamos falando de medicamentos experimentais, mas de fármacos devidamente aprovados pela ANVISA. *In casu*, não se está diante de simples experimentação de fármaco, mas sim de **ampliação do espectro de eficácia de medicamento** reconhecido pela agência reguladora.

Daí é possível concluir que a negativa apresentada pela ré é inválida e injusta, pois o tratamento de paciente sempre deve ser orientado pela melhor alternativa terapêutica indicada pelo médico assistente para a doença a que está acometido.

Assim, interpreta-se as cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que por inteligência da Súmula nº 608 do STJ aplica-se a legislação consumerista aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Dessa forma, ante a previsão de cobertura do plano para a enfermidade da parte autora, é dever da requerida fornecer o tratamento recomendado pelo médico, já que diretamente relacionado à patologia.

Não destoa desse entendimento o informativo de jurisprudência nº 632 do STJ que já tratou em suas decisões sobre o tema:

A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). STJ. 3ª Turma. REsp 1721705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018 (Info 632).

Nesse sentido, recolho precedente do eg. Tribunal de Justiça:

*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VENETOCLAX. ROL DA ANS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE ALEGA A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, NA MEDIDA EM QUE NÃO FOI DEFERIDO O PEDIDO PROVA PERICIAL. NO ENTANTO, O JUÍZO É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, CABENDO A ELE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA REALIZAÇÃO, PODENDO DETERMINÁ-LAS INCLUSIVE DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 370, DO CPC. ALIÁS, VALE DIZER QUE, NO CASO EM TELA, A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PRETENDIDA ERA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO, UMA VEZ QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS ERAM SUFICIENTES PARA EMBASAR SEU CONVENCIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. II. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O ART. 47, DO CDC, DETERMINA QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. IGUALMENTE, DEVE INCIDIR O DISPOSTO NO ART. 51, IV, § 1°, II, DO CDC, SEGUNDO O QUAL É NULA A CLÁUSULA QUE ESTABELEÇA OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INÍQUAS, QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. III. OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO OU A QUANTIDADE DE SESSÕES QUE DEVEM SER REALIZADAS, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, AINDA QUE NÃO HAJA PREVISÃO EM ROL DA ANS, O QUAL CONSTITUI APENAS REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA, CONFORME § 12 DO ART. 10 DA LEI N° 9.656/98, INCLUÍDO PELA LEI N° 14.454/2022, NÃO SENDO, PORTANTO, TAXATIVO. IV. É POSSÍVEL COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS QUANDO EXISTIR COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO, OU RECOMENDAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC), OU DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE QUE TENHA RENOME INTERNACIONAL, DESDE QUE SEJAM APROVADAS TAMBÉM PARA SEUS NACIONAIS. V. NO CASO, HÁ NOTA TÉCNICA DA PLATAFORMA E-NATJUS (NOTA TÉCNICA 139503) FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO POSTULADO EM PACIENTES COM COM LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA (CID C92.0), COMO NO CASO DA AUTORA. **VI. ADEMAIS, O MEDICAMENTO VENETOCLAX ESTÁ INCLUÍDO NO ROL DA ANS DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS PARA TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR, CONFORME ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº NORMATIVA Nº 465/2021, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). A EXISTÊNCIA DE DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE, PORQUANTO OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE VII. ALIÁS, QUANDO UM MEDICAMENTO É APROVADO PARA UMA DETERMINADA INDICAÇÃO, NÃO SIGNIFICA QUE ESTA SEJA A ÚNICA POSSÍVEL, DESCABENDO A ALEGAÇÃO DA REQUERIDA EM NÃO FORNECER OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS POR SE TRATAR DE MEDICAÇÃO OFF LABEL VIII. PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N° 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM QUESTÃO.** IX. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50412908320218210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-06-2023) [grifei]*

Por fim, o princípio da boa-fé deve reger toda a relação contratual, tal como preceitua o art. 422 do CC, não sendo plausível uma doença que possui cobertura pelo plano de saúde contratado ter o tratamento negado por interpretações restritivas da lei e das próprias cláusulas contratuais, em especial quando há risco iminente à vida da paciente.

Assim, prospera a pretensão de obrigação de fazer.

Diante do exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos movidos por **Eliana Sulzbacher Haas** contra **Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda,** para tornar definitiva a tutela provisória deferida no Evento 4, devendo o tratamento ser adequado ao laudo do evento 1, OUT4, ou outro que sobrevier para enfrentamento da mesma doença.

Sucumbente, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais arbitro em R$ 2.000,00, com fulcro no art. 85, §§2º e 8º, CPC, considerando o tempo de tramitação, o grau de zelo empregado pelo causídico e a natureza e importância da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, baixe-se em definitivo.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA RECHDEN LOBATO, Juíza de Direito**, em 20/7/2023, às 17:55:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10042570195v10** e o código CRC **8e1d36ce**.